

1501020-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... A vítima Kayck confirma igualmente o roubo o uso de arma e que havia outra pessoa junto com o que estava armado, confirmando o roubo e que houve também a subtração do celular de outras duas vítimas. Confirma que uma das vítimas, Welington estava na porta e foi o primeiro a se abordado. Esclarece que eram dois assaltantes, um ficou na porta e o outro subiu com a outra vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501020-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501020-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE SOUSA DA COSTA e outro

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14 de Fevereiro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Eder Segura, o Advogado, Dr. Alex Galanti Nilsen, OAB/SP, nº 350.335 e os acusados; LUIZ HENRIQUE SOUSA DA COSTA e SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA, apresentados presos, escoltados e algemados, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à

defesa dos acusados para apresentação da defesa preliminar. Pela defesa dos acusados, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato dos réus, vítimas e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as vítimas; Wellington Aparecido do Nascimento, Guilherme Fernandes Silva e Kayck Souza dos Santos e a testemunha, policial militar; Marcio Cavalcante de Souza. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defensoria Pública, foi dito que desistia da oitiva da testemunha, policial militar, Beatriz Vieira dos Santos, o que foi homologado. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, trata-se de ação penal instaurada em razão da prática de roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma conforme inicial. Recebida a denúncia os réus foram regularmente citados, apresentou resposta e nesta data foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e interrogados os réus. A vítima Guilherme relata que estava no andar de baixo no balcão, sendo que um dos réus anunciou o assalto apontou uma arma e mandou entregar o celular e queria dinheiro, tendo levado ele até a parte de cima onde pegou o celular de outra vítima e depois desceu pegando o celular de outra vítima, no total foram três aparelhos celulares subtraídos, dizendo que viu a polícia com os dois réus presos no local. A vítima fez o reconhecimento em juízo nesta data, reconhecendo um dos réus. A vítima Kayck confirma igualmente o roubo o uso de arma e que havia outra pessoa junto com o que estava armado, confirmando o roubo e que houve também a subtração do celular de outras duas vítimas. Confirma que uma das vítimas, Wellington estava na porta e foi o primeiro a se abordado. Esclarece que eram dois assaltantes, um ficou na porta e o outro subiu com a outra vítima e ele mesmo. Também reconheceu um dos réus como autor dos fatos. A vítima Wellington ouvida nesta data relata que estava do lado de fora fumando e aí chegaram os dois réus sendo que anunciaram o assalto e ele ficou com um dos réus enquanto que o outro subiu e voltou com os celulares das outras vítimas e o réu armado chegou perto dele e apontou a arma e mandou entregar o celular se não levaria um tiro. Esclarece que quando os criminosos saíram ele tentou seguir os referidos mas o armado mandou ele voltar se não o mataria. E depois ainda saiu de novo atrás deles e viu eles correndo e o momento em que foram abordados pela viatura policial, tendo certeza do momento em que foram presos. A vítima fez reconhecimento em juízo dos dois réus mas se confundiu em relação a um deles, trocando nos números. O réu reconhecido pelas outras vítimas foi o que entrou e que elas tiveram maior contato pessoal e o outro réu foi reconhecido do pela vítima que estava do lado de fora, sem qualquer dúvida. O policial Marcio relata que estavam em patrulhamento quando os elementos viram a viatura e tentaram fugir, sendo abordados tendo encontrado em poder deles três celulares e que teria soltado a arma no início da rua, tendo sido a arma encontrada no local onde o réu disse que havia dispensado a referida. Relata ainda que as vítimas do roubo se aproximaram e reconheceram os réus como autores do roubo e reconheceram os celulares subtraídos. Não há razão para duvidar-se da narrativa das vítimas sendo que o reconhecimento feito por elas foi seguro de acordo com o que cada uma viu mais precisamente e cada uma delas viu cada

um dos réus em momentos distintos, sendo que eram pessoas desconhecidas para as vítimas até aquela data. A narrativa do policial também deve ser considerada pois estava no exercício da função e confirma a narrativa das vítimas. O réu Samuel declara que praticou o delito e alega que agiu sozinho, confessando a prática do delito, procurando isentar a pessoa de Luiz Henrique. Alega que ele mesmo estava armado. O réu Luiz Henrique nega a prática do delito, alegando que foi ao local para comer uma pizza, dizendo que preferiu nem entrar. A confissão de Samuel é parcial, sendo que a negativa de Luiz e a afirmação de Samuel nesse sentido não deve ser acolhida frente a narrativa policial e das vítimas com a visão de cada uma delas, deixando claro que ambos os réus estavam agindo em conjunto não sendo cabível acolher a afirmação dos acusados nesse sentido. A arma apreendida foi periciada com o laudo juntado em fls.159/164. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia. No tocante a pena, há que se considerar a reincidência dos réus conforme FA e certidões juntadas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal para ambos, bem como seja reconhecido o concurso de agentes e o emprego de arma no patamar de aumento de 2/3 da pena, comprovados por todo o conjunto probatório, além do reconhecimento do concurso formal e seu aumento frente a se tratar de três vítimas. A confissão judicial de Samuel não deve ser considerada frente ao fato de que não esclareceu de forma clara e espontânea os fatos. Deve ser fixado o regime prisional inicialmente fechado para ambos os réus neste caso frente as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. Dada a palavra à defesa dos acusados, assim se manifestou: MM Juiz, SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA E LUIS HENRIQUE SOUZA DA COSTA, já qualificado nos autos em epígrafe, foi processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, vem à defesa apresentar alegações finais. Computando-se os autos, tem-se que a absolvição de fato é medida de rigor. Senão vejamos: Da Nulidade dos Reconhecimentos Fotográficos Realizados em Sede Administrativa. Da violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. Após análise dos autos, verifica-se que estamos diante de hipótese de declaração de nulidade dos reconhecimentos pessoais produzidos em sede inquisitiva, eis que não atenderam aos ditames do artigo 226, do CPP, devendo-se, por corolário, desentranhá-los do processo, conforme mandamento irrevogável do artigo 157, caput, do CPP. Bem sabido que, para que uma prova seja considerada legal, ela deve ser produzida de acordo com o ordenamento jurídico vigente, a fim de que o magistrado possa proceder à sua avaliação e valoração dentro do cotejo probatório sob o manto do livre convencimento motivado (artigo 155, caput, do CPP). O reconhecimento pessoal, de coisas ou até mesmo fotográfico (não previsto no ordenamento processual penal [meio de prova anômala]), para surtir efeitos endoprocessuais, deve estrita obediência à legalidade, neste caso, ser realizado sob o procedimento previsto no artigo 226, do CPP, que funciona da seguinte forma: Artigo 226, caput, CPP – Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa [ou coisa], proceder-se-á da seguinte forma: Inciso I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Inciso II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; Inciso III – Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; Inciso IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. (grifos nossos). Ve-se claramente da leitura acima, quais os requisitos que revestem de legalidade o ato de reconhecimento: a) descrição, por parte do reconhecedor, da pessoa (coisa) a ser reconhecida; b) colocação da pessoa a ser reconhecida com outras que com ela tiveram semelhança e; c) lavratura de auto pormenorizado. Ocorre que são vários os vícios detectados no presente processo quanto aos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítima Ricardo, razão porque tais procedimentos devem ser considerados absolutamente nulos e ilegais. Nota-se claramente, pelos termos de

reconhecimento acima apontados, que estes não se mostraram estritamente obedientes ao procedimento previsto na norma, eis que não há nos autos o conjunto das fotos que foram exibidas aos reconhecedores, tão somente repousa nos autos foto isolada do acusado. Este proceder demonstra caráter indutivo, eis que inibe justamente a segurança que reclama o ato de reconhecimento pessoal. Veja-se que o inciso II do artigo 226 ordena que, quando possível, a pessoa a ser reconhecida será colocada ao lado de outras que com ela tiverem semelhança. O espírito deste comando é justamente o de atribuir maior carga valorativa ao reconhecimento, que reclama do reconhecedor concentração e a utilização de características específicas para individualizar a pessoa que se pretende reconhecer. Esta senda, simetricamente, no caso de reconhecimento fotográfico, imperioso que exista nos autos as fotos que foram mostradas aos reconhecedores a fim de que este juízo possa aferir se houve ou não indução, ainda que involuntária, durante o procedimento. Não há como saber se foram mostradas às vítimas fotografias de pessoas semelhantes ou não ao acusado, com características físicas e faciais similares, altura, cor de cabelo, etc. Há nos autos, somente uma foto isolada do acusado, a qual não se sabe a origem. Assim, mormente no reconhecimento fotográfico (que ante a pacificada jurisprudência não goza de credibilidade probatória autônoma), dever-se-ia a autoridade policial proceder com estrita obediência ao passo a passo reclamado ao ato, reclamando maior cautela do investigador no procedimento, o que no caso dos autos, por certo, fora negligenciado. O inquérito para apurar um crime de roubo não pode ser presidido de tal maneira. Conclui-se, diante do exposto, que os procedimentos de reconhecimento fotográfico realizados pelas já citadas vítimas são absolutamente nulos. Não servem de prova no presente processo. Trata-se de procedimento indutivo e em total desacordo com as mezinhas regras processuais previstas no ordenamento processual penal pátrio. É prova ilegal e deve ser desentranhada do processo. Pois bem. É entendimento pacífico por parte do STJ que é possível o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, mas desde que, em Juízo, sejam observadas as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC 136.147, 5ª Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 03/11/2009). É dizer, eventual irregularidade cometida no inquérito policial estaria sanada na fase judicial, caso o juízo processante realizasse, agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas as formalidades legais descritas no art. 226 do CPP. Ou seja, admite-se o reconhecimento fotográfico apenas como instrumento-meio; nunca como ato probatório autônomo. Aliás, o modo de realização do reconhecimento judicial não guardou relação alguma com as formalidades do art. 226 do CPP, pois (i) o acusado não foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança, além de (ii) não ter sido feito auto pormenorizado de reconhecimento (incisos II e IV, respectivamente, do art. 226 do CPP). Portanto, não foi realizado nenhum reconhecimento pessoal – dotado da formalidade prevista em lei – a ponto de substituir o (ilegal) reconhecimento por fotografia feito perante a autoridade policial. Conclui-se que o reconhecimento fotográfico funcionou, no caso hipotético, como ato probatório autônomo, substituindo o reconhecimento pessoal. Como corolário lógico, levando em consideração que – em se tratando de processo penal – forma é garantia, aceitar a validade do reconhecimento fotográfico de forma isolada, não coadunado com demais elementos judiciais de prova, é uma informalidade que padece de total ilegalidade. É o próprio STJ que corrobora esse entendimento, ao afirmar que o “reconhecimento fotográfico somente deve ser considerado como forma idônea de prova, quando acompanhada de outros elementos aptos a caracterizar a autoria do delito” (HC nº 27.893, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 03/11/2003). E a Corte complementa tal raciocínio ao referir que a produção de provas na fase inquisitorial “deve observar com rigor as formalidades legais tendentes a emprestar-lhe maior segurança, sob pena de completa desqualificação de sua capacidade probatória” (HC 56.723, Sexta Turma, Rel. Ministro Paulo Medina, DJ 11/12/2006). Patente, pois, a ilegalidade do reconhecimento por meio fotográfico realizado em detrimento do denunciado Everton, pois utilizado de forma isolada no feito, tornando-se eloquente e necessária a declaração da nulidade de tal ato, forte ao art. 564, IV, do CPP – devendo ser desentranhado dos autos e consequentemente desconsiderado para fins de análise probatória. Sobre a prova

ilícita, reza a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVI, que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio ilícitos”. O artigo 157, caput, do CPP, também esclarece: “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”. Reza também o artigo 564, inciso IV, do CPP que ocorrerá nulidade quando se constatar omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. No presente caso a formalidade essencial apontada é a estrita observância dos requisitos do artigo 226, do CPP, o que, conforme sobejamente demonstrado, não ocorreu. Sobre dito reconhecimento, a jurisprudência também alberga a tese alhures defendida, conforme exemplificam os julgados abaixo: Apelação Crime nº 70035614999, Sexta Câmara Criminal do RS. Julgado em 27.05.2010 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PROVA RECONHECIMENTOS. PROVA VALIDADE. REQUISITOS E CAUTELAS LEGAIS. PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. Não há previsão legal ao reconhecimento fotográfico, motivo por que se parte da premissa de que a identificação por fotografia não é substitutiva da identificação pessoal, não podendo, portanto, ser admitido como ato probatório autônomo. O reconhecimento fotográfico há de obedecer, na esteira dos precedentes dos Tribunais superiores, as regras contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento em juízo há de guardar as cautelas, de modo a não haver identificação automática do imputado. O reconhecimento fotográfico, ou por meio de fotografias, não guarda o mesmo valor probatório do pessoal, em face dos empecilhos no estabelecimento da correspondência entre o sujeito e a fotografia, situando-se em um plano probatório complementar e não prima facie (...). (grifo nosso). A produção de provas na fase inquisitorial deve observar com rigor as formalidades legais tendentes a emprestar-lhe maior segurança, sob pena de completa desqualificação de sua capacidade probatória. (STJ - HC 56.723, Sexta Turma, Rel. Ministro Paulo Medina, DJ 11/12/2006). Portanto, ante as razões expostas, pela inobservância do procedimento mandamental do artigo 226, do CPP, requer a este r. Juízo que se digne em declarar a nulidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas Antônio dos Santos Aleixo (fls. 31) e Iago Alves da Costa (fls. 11), determinando o seu imediato desentranhamento dos autos, tudo com fundamento e sob pena de violação do artigo 5º, inciso LVI, da CF/88, artigo 8º, da CADH e artigo 564, inciso IV, c/c artigo 226 e 157, caput, todos do CPP. No Mérito. ANÁLISE DE DEPOIMENTOS: Na sala de AUDIÊNCIA COM O RÉU ALGEMADO, as vítimas não reconheceram, NÃO LUIZ fizeram o reconhecimento o réu como autor do delito em tela. Foram claros e objetivos em não reconhecer, sem qualquer resquício de dúvidas. A negativa de autoria do réu LUIZ, merece toda credibilidade, pois resta flagrantemente verossímil e totalmente corroborada com o depoimento das testemunhas de acusação, inclusive das vítimas. O acusado é pessoa trabalhadora, possui antecedentes criminais, mas isso faz parte do seu passado, ESTAVA COM REGISTRO EM CARTEIRA NA EPOCA DOS FATOS. Todos os depoimentos são condizentes com o depoimento do acusado, que declarou nada saber sobre tal roubo, que teria acontecido nesta cidade. Verifica-se nobre Juiz, que todas as versões são uníssonas e nenhuma destoia da realidade. Deste modo, é evidente a fragilidade dos meios de prova colhidos em desfavor dos acusados, tornando inviável a responsabilização penal do mesmo pelo evento noticiado na denúncia. Analisando o conjunto probatório produzido, verifica-se que o roubo imputado aos réus não foram comprovados em forma tal que autorize certeza quanto à autoria. A prova é paradoxal e desautoriza condenação.

Os indícios de autoria foram suficientes para o oferecimento da denúncia como, brilhantemente, fez o Ministério Público. Contudo, após o término da instrução processual tais indícios não permanecem. Os elementos do inquérito policial não foram confirmados em Juízo. Por conseguinte, não há que se falar em certeza necessária para condenação, pois tal certeza deveria ser produzida durante o deslinde da instrução processual, o que não se verificou in casu. A presunção de culpa é relativa, devendo a certeza ser produzida durante o deslinde da instrução processual. Excelência, não há certeza plena de que seja a acusada um dos autores do roubo por tudo o que aqui já dito. Nobre julgador, conforme se vê, a simples presunção de culpa não autoriza a condenação de quem quer que seja. Sem prova plena e verdadeira a condenação será sempre uma injustiça e a execução da sentença uma

violência! Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis de certeza geral, que evidenciam o delito e a autoria, não bastando à alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio". (Ap. Criminal 47.335.3-3a C.J. 18/05/87 – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Re. Des. Silva Lemes). A despeito da materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. ), autos de reconhecimento de pessoa (fls.), pelo auto de exibição e apreensão (fls. ), pelo auto de entrega (fls. ), não se comprovou a autoria dos fatos narrados na denúncia, e desta forma, requer a ABSOLVIÇÃO do acusado EVERTON. O réu deve, portanto, ser absolvido, sendo esta a única certeza dos autos. O restante, não ultrapassa o terreno da probabilidade, o que difere da certeza necessária para uma condenação. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL-DO REU LUIZ. Na fase inquisitiva o réu negou os fatos, agindo assim acertadamente, uma vez que em tal fase não são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por seu turno em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva. Informou que estava morando no Guarujá/SP. Que os milicianos ao saberem que o Denunciado tinha condenação anterior, o prenderam, e frisaram "vamos ver em que o juiz vai acreditar, na gente que é polícia, ou em você que já tem passagem". Que os policiais o apresentaram para as vítimas no local dos fatos como sendo o autor do delito. Negou portar qualquer arma. De fato, essa é a versão que deve prevalecer nos autos. Nada, absolutamente nada, foi apreendido em poder do Apelante relativo ao roubo. O reconhecimento é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma COMO CERTA a identidade de outra. E como é sabido, o reconhecimento de pessoas deve ser feito com toda cautela, haja vista que se trata de um procedimento relativo, pois a vítima na ânsia de encontrar o seu algoz pode muito bem confundir-se apontando pessoa diversa daquela que praticou a conduta delituosa contra si. O denunciado labora, possui portanto, ocupação lícita. O denunciado é pessoa trabalhadora, honesta, possui ocupação lícita, residência fixa, documentos comprobatórios já anexados no processo. Assim, tem-se que na delegacia as vítimas agiram precipitadamente responsabilizando pessoas inocentes, no anseio de encontrar um responsável por sua desdita. As testemunhas arroladas pela acusação, embora tenham confirmado a autoria da infração, seus depoimentos devem ser recebidos com a devida cautela. Não se busca desmerecer o trabalho e o depoimento de um policial que tanto faz bem à sociedade, entretanto, resta claro no depoimento dos mesmos, a sede de responsabilizar penalmente o acusado, a fim de oferecer uma pronta resposta à sociedade, ainda que trazendo elementos pouco sustentáveis. Ainda, face as contradições no depoimento das vítimas, NOS TERMOS DO ARTIGO 155, DO CPP, não há razão para condenação do réu, vejamos: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008). De fato, considerando os elementos de prova contidos nesses autos, não há que se falar em condenação do réu. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Não havendo provas que confirmem, com plena certeza, a hipótese denunciada pela acusação, impositiva a ratificação da absolvição. A vítima nem sequer foi ouvida em juízo, não havendo por parte desta reconhecimento judicial dos acusados. Ademais, o restante da prova oral revela-se frágil a viabilizar o acolhimento da versão acusatória, haja vista não ter constado do acervo probatório certeza a respeito da ação conjunta dos réus para perpetrar o fato denunciado, assim como as agressões asseveradas não condizem necessariamente à consecução do delito patrimonial. A versão acusatória é de ação dos três recorridos, mas a prova demonstrou que apenas um deles teria cometido subtração bagatelar que agressões ocorreram em momento anterior, não havendo demonstração de liame de vontades. Correta, portanto, a hipótese da sentença de que seria caso de lesões corporais, mas, sem auto de exame de corpo de delito, fica imaterizaliado o fato, assim como de furto bagatelar atípico. APELO. Sendo assim, diante do que foi colhido nos autos, ou seja, negativa do réu em relação ao

roubo, bem como, as contradições nas declarações das vítimas, não há que se falar em condenação do réu por roubo. Contraditório, portanto, o depoimento do Policial, razão pela qual deve ser recebido com reservas. Como para condenar é preciso prova inconteste, que conduza à certeza, a dúvida vem em benefício do apelante, prevalecendo, assim, o princípio da presunção de inocência. Condenação criminal exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a sua autoria, não bastando a convicção subjetiva formada na consciência do julgador. Nesse sentido: Roubo duplamente majorado. Subtração, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, de roupas e correntes de estabelecimento comercial. Pretendida absolvição por insuficiência de prova. Admissibilidade. Dúvida quanto à autoria. Acusado não reconhecido pela vítima. Negativa em juízo. Ausência de certeza para firmar condenação criminal. Princípio do in dubio pro reo. Apelo provido para absolvê-lo com base no artigo 386, VII, do CPP. (TJ-SP - APL: 00045946220118260587 SP 0004594-62.2011.8.26.0587, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 27/08/2013, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/08/2013). ROUBO QUALIFICADO Apelo do réu Ricardo Pleito de exclusão da reparação "ex delicto" rejeitado Pedido formalizado pelo Ministério Público na denúncia, tendo por base laudo de avaliação do veículo subtraído Recorrente que teve oportunidade de apresentar contraprova durante toda a instrução criminal, mantendo-se, todavia, inerte Reparação civil mantida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. Apelo do Ministério Público Pretendida condenação do corréu Rodrigo Impossibilidade Acusado não reconhecido pela vítima Ausência de prova inequívoca acerca de sua participação no crime Observância do princípio do "in dubio pro reo" Absolvição mantida DOSIMETRIA Qualificadora referente ao concurso de agentes não demonstrada Requerimento afastado. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00002199020128260099 SP 0000219-90.2012.8.26.0099, Relator: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 10/06/2014, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/06/2014). Destarte, diante do parco conjunto probatório constante nos autos, aliada a negativa do Apelante, a absolvição é medida imperativa. DO JUÍZO DE REPROVAÇÃO FACE A CONDUTA DO ACUSADO. Juiz de Direito, especialmente o criminal, julga o homem à luz de sua conduta, em tese, criminosa, mas o julga em atenção a todos os seus problemas pessoais, sociais, e em observância às suas aflições. Portanto, para a aplicação da lei penal, através da prestação jurisdicional, nos casos em se tenha a absoluta certeza do cometimento do crime, que não é o caso, será preciso especial atenção aos motivos e razões que o levaria a cometer a infração penal. Nesta esteira de raciocínio, poderá o juiz, em atenção ao princípio da culpabilidade, entender ser desnecessário censurar a conduta do agente infrator. Isto, considerando-se a realização de uma conduta criminosa. No caso em tela, nada obstante o acusado não realizar o tipo penal descrito na peça inaugural, o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de condenação, é certo que em seu testemunho em juízo, o acusado negou a prática de qualquer delito, esclarecendo que naquele dia passou na casa de Júlio César e lhe deu uma carona para tomarem um lanche. A conduta do acusado em momento algum demonstra intenção de impor medo ou violência à vítima, seja qual for a sua modalidade, de modo que aplicar a ele a sanção penal prevista seria violar o princípio da culpabilidade, posto que não há pena e nem crime sem a presença desta. Portanto, deverá, desta feita, em atenção à sua culpabilidade, por absoluta insuficiência probatória, ser absolvido da grave imputação que sobre o acusado paira. Senão também vejamos: "A condenação exige prova irrefutável da autoria. Quando o suporte de acusação enseja dúvida, o melhor é absolver." (TARJ - AP - Rel. Erasmo do Couto - RT 513/479). Da Confissão como atenuante da pena - REU SAMUEL. Prescreve o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, que a confissão espontânea da autoria do crime, perante autoridade, é circunstância que sempre atua a pena. Assim, a princípio, entende-se que se o agente confessar espontaneamente a autoria do fato delituoso, em presença de autoridade, faz jus à circunstância legal genérica de redução de pena. De início, cabe ressaltar que o fundamento desta atenuante é meramente político-criminal (ZAFFARONI e PIERANGELI, p. 790), isto é, "baseia-se fundamentalmente em considerações político-criminais (v.g., exigências da prevenção especial,

favorecimento da administração da justiça)" (PRADO, p. 268). Trata-se, pois, "de regra de política processual para facilitar a apuração da autoria e prevenir a eventualidade do erro judiciário" (DOTTI, p. 622). Assim, "a confissão espontânea é considerada um serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa" (CAPEZ, p. 455). Pois bem. Do texto legal supracitado é possível extrair, então, que são dois os requisitos (simultâneos) para o reconhecimento da atenuante: a) existir confissão espontânea de autoria de crime; e b) seja feito perante autoridade. Preenchidos os dois requisitos, em tese, o agente tem sua sanção penal atenuada, vez que se trata de "direito público subjetivo do réu" (STF. HC 106.376/MG. Rel. Carmen Lúcia. T1. Julg. 01.03.2011). Vejamos cada um dos requisitos: Confessar significa "Declarar (o acusado) sua responsabilidade em crime que lhe é atribuído" (GUIMARÃES, p. 195). É, em outras palavras, o reconhecimento do agente pela prática de algum fato. Para NUCCI, "Confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, (...) a prática de algum fato criminoso" (p. 253/254). No entanto, para a maioria, não basta que haja a confissão. Deve ela ser espontânea. Espontâneo é aquele ato "De livre vontade; voluntário" (FERREIRA, p. 271). Destarte, a confissão para ser considerada como atenuante deve ser "fundada em decisão autônoma do autor, independente da natureza da motivação (egoísmo, altruísmo, nobreza etc.)" (SANTOS, p. 335), ao contrário do entendimento damasiano (de que "o que importa é o motivo da confissão, como, p. ex., o arrependimento, demonstrando merecer pena menor, com fundamento na lealdade processual" - p. 578). Não há, nos dias atuais, impedimento legal para que se aplique a pena a quem do seu mínimo legal. O art. 68 do CP, não impõe nenhum obstáculo. Aliás, considerando-se o art. 65 do CP, as circunstâncias atenuantes sempre devem atenuar a pena. Qualquer entendimento em sentido contrário estaria inviabilizando um direito do sentenciado. Negar a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal ao sentenciado, estaríamos aceitando em nosso ordenamento jurídico uma interpretação restritiva contra o réu, o que não pode ser admitido. Além de se estar violando, de forma muito clara, o princípio constitucional da individualização da pena, assim como o da proporcionalidade e da culpabilidade. DESTA FORMA REQUER NA FASE DE DOSIMERIA DA PENA A APLICACAO DA PENA ABAIXO DO MINIMO LEGAL, EM ANALISE A TODAS CIRCUNTANCIAS FAVORAVEIS AO REU. DA REDUCAO PELO ARTIGO 14 DO CODIGO PENAL. O crime tem um caminho para a sua concretização, o qual é chamado de "iter criminis". Nesse caminho, existem quatro fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Para alguns, também há o exaurimento, que é posterior à consumação. Uma vez iniciados os atos executórios (fase da execução), ainda pode haver um longo caminho para que ocorra a consumação da infração penal. Quando se ingressa na fase de execução, dois fenômenos são possíveis: a tentativa ou a consumação. Quando utilizo a expressão "tese defensiva", não pretendo - como pensam os punitivistas -, buscar meios ilegais para a absolvição ou a redução da pena. O objetivo é apenas estabelecer um julgamento justo para os acusados, de modo que, se for o caso, sejam condenados nos estritos limites da lei. É papel da defesa apresentar ao Juízo todas as alegações que possam melhorar a situação do acusado, sempre agindo de acordo com as disposições constitucionais e infraconstitucionais e buscando suporte doutrinário e jurisprudencial. Nesse diapasão, insta ressaltar que o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que, em caso de tentativa, a pena será diminuída de um a dois terços. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o seu entendimento sobre a definição da fração aplicável em caso de tentativa, "in verbis": CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA CONCRETA QUE EXCEDE ÀQUELA PRÓPRIA AO CRIME. ART. 14, II, DO CP. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte reconhece o critério de



diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...] (HC 376.714/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). Em outras palavras, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em caso de enorme distanciamento entre a execução do crime pelo agente e a consumação desse mesmo crime, a pena deve ser menor, razão pela qual se aplica uma fração de diminuição mais elevada, como, por exemplo, dois terços. Inicialmente, caso o Juiz considere fração diversa de dois terços, deverá fundamentar a sua decisão. Dois terços é a fração mais favorável, pois é aquela que mais diminui a pena do acusado. Se o julgador, na dosimetria da pena, aplicar outra fração - que resultará em uma diminuição menos significativa da pena -, deverá motivar detalhadamente com base nos fatos provados. Noutros termos, precisará demonstrar que o "iter criminis" foi consideravelmente percorrido, chegando próximo à consumação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem decisão afirmando que a redução deve ser feita no patamar de dois terços da pena numa hipótese em que o réu foi preso logo depois de ter a posse dos valores subtraídos, "in verbis"; CÓDIGO PENAL. ART. 155, CAPUT. FURTO SIMPLES. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...] TENTATIVA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO. O iter criminis percorrido ficou longe da consumação, tendo em vista ter sido o réu preso imediatamente após se apossar dos valores. Aumentada a fração de redução para 2/3. [...] (Apelação Crime Nº 70055869119, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/10/2013) [grifei]. Os ministros destacam a pertinência da análise na fixação de penas: "Conforme o entendimento desta corte, a diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do crime. Se integralmente percorrida a fase execução, deve ser reconhecida a incidência da fração mínima de redução", resume uma das ementas disponíveis na pesquisa. O conceito de iter criminis, definido como "caminho do crime", refere-se ao processo de evolução do delito; e, na análise do contexto dos fatos, apura a gravidade da conduta, a proximidade da execução, o risco oferecido, entre outros fatores importantes para a definição da culpabilidade do réu. 1. AS FASES DO ITER CRIMINIS. 1.1 - Conceito. Segundo o autor Cleber Masson (2015, p.355), o iter criminis ou caminho do crime, corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Neste mesmo diapasão, leciona o autor Cezar Roberto Bitencourt (2012, p.522), como em todo ato humano voluntário, no crime a ideia antecede a ação é no pensamento do homem que se inicia o movimento delituoso, e a sua primeira fase é a ideação e a resolução criminosa. Há um caminho que o crime percorre, desde o momento que germina, como ideia, no espírito do agente, até aquele em que se consuma no ato final. A esse itinerário percorrido pelo crime, desde o momento da concepção até aquele em que ocorre a consumação, chama-se iter criminis e compõe-se de uma fase interna (cogitação) e de uma fase externa (atos preparatórios, executórios e consumação), ficando fora dele o exaurimento, quando se apresenta destacado da consumação. O autor Damásio de Jesus nos ilustra um exemplo em que o agente, com intenção de matar a vítima (cogitação), adquire um revólver e se posta de emboscada à sua espera (atos preparatórios), atirando contra ela (execução) e lhe produzindo a morte (consumação). É na verdade o iter criminis o caminho a ser percorrido pelo crime a qual antecede o fato criminoso, ou seja, o agente antes de praticar o delito ele passa por uma série de etapas em que depois de realizadas, logo então é concretizado o delito pelo autor. 1.2 - Fase interna: Cogitação. Na cogitação não existe ainda a preparação do crime, o autor apenas mentaliza, planeja em sua mente como vai ele praticar o delito, nesta etapa não existe a punição do agente, pois o fato dele pensar em fazer o crime não configura ainda um fato típico e antijurídico pela lei, sendo irrelevante para o direito penal. Enquanto encarcerada nas profundezas da mente humana, a conduta é um nada, totalmente irrelevante para o direito penal. Somente quando se rompe o claustro psíquico que a aprisiona, e materializa-se concretamente a ação, é que se pode falar em fato típico (CAPEZ, 2008, p.241). 1.3. Fase externa: Preparação. Segundo o ilustre Fernando Capez (2008, p.241), é a prática dos atos imprescindíveis à execução do crime. Nesta

fase ainda não se iniciou a agressão ao bem jurídico, o agente não começou a realizar o verbo constante da definição legal (núcleo do tipo), logo o crime ainda não pode ser punido. É a preparação da ação delituosa que constitui os chamados atos preparatórios, os quais são externo ao agente, que passa da cogitação à ação objetiva; arma-se dos instrumentos necessários à prática da infração penal, procura o local mais adequado ou a hora mais favorável para a realização do crime (BITENCOURT, 2012, p.523). O agente na preparação ele usa dos meios indispensáveis para a prática da infração penal, municiando-se dos meios necessários para se chegar a concretização do ilícito penal. É o caso por exemplo do agente comprar uma arma de fogo, para a prática futura de um crime de homicídio. Conforme esclarece Cleber Masson (2015, p.357), em casos excepcionais, é possível a punição de atos preparatórios nas hipóteses em que a lei optou por incriminá-los de forma autônoma. São os chamados crimes-obstáculo. É o que se dá com os crimes de fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfíxiante (CP, art. 253), incitação ao crime (CP, art.286), associação criminosa (CP, art. 288) e petrechos para a falsificação de moeda (CP, art. 291), entre outros.

1.4 Execução. Segundo o autor Cezar Roberto Bitencourt (2012, p.523), dos atos preparatórios passa-se, naturalmente, aos atos executórios. Atos de execução são aqueles que se dirigem diretamente à prática do crime, isto é, a realização concreta dos elementos constitutivos do tipo penal. Nos dizeres de Cleber Masson (2015, p.357), a fase da execução, ou dos atos executórios, é aquela em que se inicia a agressão ao bem jurídico, por meio da realização do núcleo do tipo penal. O agente começa a realizar o verbo (núcleo do tipo) constante da definição legal, tornando o fato punível. Segundo o autor o ato da execução deve ser idôneo e inequívoco. O ato idôneo é o que se reveste de capacidade suficiente para lesar o bem jurídico penalmente tutelado e o ato inequívoco é o que se direciona ao ataque do bem jurídico, almejado a consumação da infração penal e fornecendo certeza acerca da vontade ilícita, tendo como exemplo um disparo de arma de fogo efetuado na direção da vítima é unívoco para a prática de um homicídio, diferente de um disparo efetuado para o alto. É no ato executório que se inicia a ofensa ao bem jurídico penalmente protegido pelo direito penal, nesta etapa, o agente ele age com o dolo de agressão ao bem da vítima, realizando a conduta do núcleo do verbo, ou seja, praticando o fato típico e antijurídico do crime, momento este que a sua conduta passa a ser reprovado pela lei e com isto, tendo a sua punição.

1.5. Fronteira entre o fim da preparação e o início da execução. De acordo com o entendimento de Fernando Capez (2008, p.242) é muito tênue a linha divisória entre o término da preparação e a realização do primeiro ato executório. Torna-se, assim, bastante difícil saber quando o agente ainda está preparando ou já está executando um crime. O melhor critério para tal distinção é o que entende que a execução se inicia com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito. Enquanto os atos realizados não forem aptos à consumação ou quando ainda não estiverem inequivocamente vinculados a ela, o crime permanece em sua fase de preparação. Desse modo, no momento em que o agente aguarda a passagem da vítima, escondido atrás de uma árvore, ainda não praticou nenhum ato idôneo para causar a morte daquela, nem se pode estabelecer indubitosa ligação entre esse fato e o homicídio a ser praticado. Por essa razão, somente há execução quando praticado o primeiro ato capaz de levar ao resultado consumativo e não houver nenhuma dúvida de que tal ato destina-se à consumação. Nos atos preparatórios o agente não pratica o ato idôneo e inequívoco para a consumação, não há ainda o fato típico realizado em sua conduta, já na execução o autor pratica o ato direcionado a realização do fato típico, do núcleo do tipo, para a realização do delito. Segundo o autor Cleber Masson (2015, p.358), inúmeras teorias apresentam propostas para a solução do impasse. Dividem-se inicialmente em subjetiva e objetiva, esta última se ramifica em diversas outras. Vejamos as mais importantes. Teoria subjetiva: não há transição dos atos preparatórios para os atos executórios. O que interessa é o plano interno do autor, a vontade criminosa, existente em quaisquer dos atos que compõem o iter criminis, logo, tanto a fase da preparação como a fase da execução importam na punição do agente. Por essa teoria tanto a preparação como a execução traz para o autor do crime a punição, pouco importando a fase da preparação do delito, ou seja,

no momento em que o autor se prepara com os elementos necessários para a infração, ele já está sujeito por uma punição da lei. Teoria objetiva: os atos executórios dependem do início de realização do tipo penal, o agente não pode ser punido pelo seu mero querer interno, é imprescindível a exteriorização de atos idôneos e inequívocos para a produção do resultado lesivo. Essa teoria, todavia, se divide em outras: Teoria da hostilidade ao bem jurídico: atos executórios são aqueles que atacam o bem jurídico, enquanto os atos preparatórios não caracterizam afronta ao bem jurídico, mantendo inalterado o estado de paz. Teoria objetiva - formal ou lógica - formal: ato executório é aquele em que se inicia a realização do verbo contido na conduta criminosa. Exige tenha o autor concretizado efetivamente uma parte da conduta típica, penetrando no núcleo do tipo. Tendo como exemplo, em um homicídio, o sujeito, com golpes de punhal, inicia a conduta de matar alguém. É a preferida pela doutrina pátria. Entende-se que esta teoria seja a mais coerente, pois para se realizar os atos executórios o agente infrator ele precisa realizar o verbo do tipo penal, desta forma se iniciará a agressão ao bem jurídico, tornando o fato punível. Teoria objetiva - material: atos executórios são aqueles em que se começa a prática do núcleo do tipo, e também os imediatamente anteriores ao início da conduta típica, de acordo com a visão de terceira pessoa, alheia aos fatos. O juiz deve se valer do critério do terceiro observador para impor a pena. Exemplo: aquele que está no alto de uma escada, portando um pé de cabra, pronto para pular um muro e ingressar em uma residência, na visão de um terceiro observador, iniciou a execução de um crime de furto. Nesta teoria, fica evidente que ela também, usa o núcleo do tipo para se chegar na fase da execução, porém, ela usa os atos anteriores ao início da conduta delituosa, ou seja, precisa de uma terceira pessoa para observar o fato criminoso e este dirá se através dessa conduta foi praticada o crime pelo autor. Teoria objetivo - individual: atos executórios são os relacionados ao início da conduta típica, e também os que lhe são imediatamente anteriores, em conformidade com o plano concreto do autor. Portanto, diferencia-se da anterior por não se preocupar com o terceiro observador, mas sim com a prova do plano concreto do autor, independentemente de análise externa. Exemplo: A, com uma faca em punho, aguarda atrás de uma moita a passagem de B, seu desafeto, para matá-lo, desejo já anunciado por diversas pessoas. Quando este se encontra a 200 metros de distância, A fica de pé, segura firme a arma branca e aguarda em posição de ataque seu adversário, surge a polícia e o aborda. Para essa teoria, poderia haver a prisão em flagrante, em face da caracterização da tentativa de homicídio, o que não se dá na teoria objetivo formal. Já nesta teoria não existe a figura de uma terceira pessoa, para validar a conduta típica, é preciso da prova no plano concreto, independente de que a observa, ou seja, a conduta criminosa e conhecida por diversas pessoas, mas se for feita uma análise pela teoria objetivo formal, não haveria se quer ainda o crime, pois estaria diante da fase da preparação. DESTA FORMA NOBRES DESEMBARGADORES RESTOU CLARO QUE O REU AQUI EM QUESTAO NEM SE QUER ULTRAPASSOU A FASE DE EXECUCAO POIS COMO DITO PELO PROPRIOS POLICIAIS E AS VITIMAS O REU FOI SURPREENDIDO A POUCOS METROS DO LOCAL. DA DOSIMETRIA DA PENA. Aqui também o cálculo da pena se encontra equivocado. Sabe-se que, por força do Art. 68 do CP a dosagem da pena se faz pelo método trifásico de Nelson Hungria. Na 1ª fase (pena-base) Art. 59 do CP deve-se enfrentar as 8 (oito) circunstâncias judiciais, não devendo especificar o quantum sancionatório para cada circunstância reconhecida, mas, deve-se deixar bem claro quantas circunstâncias favorecem e quantas desfavorecem o sentenciando. Conforme doutrina de Rogério Greco quando as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP são, em sua maioria, desfavoráveis ao acusado, a sentença deve calcular a pena-base no mínimo legal previsto, acrescido de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Não sendo o caso de se reconhecer a maioria das circunstâncias judiciais, então, o decreto condenatório, nesta fase, deve ficar apenas no quantum da pena mínima prevista. Nesse caso deveria a pena-base ficar no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão para cada conduta crime ventilada. DA PENA. Clama à V.Exa., que a pena base seja fixada no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são favoráveis. DAS CAUSAS DE AUMENTO. O crime foi praticado com o dolo normal do tipo penal, haja vista que em momento algum houve humilhação às vítimas. Razão pela qual, em relação

às causas de aumento, requer sejam fixadas em sua fração mínima. Do Princípio da Ofensividade. Da leitura atenta aos autos que geraram a condenação pode-se notar a inexistência de perícia na arma supostamente utilizada no delito. Devemos